

1500145-02.2021.8.26.0210

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDERSON VALENTE

Comarca: Guaíra

Foro: Foro de Guaíra

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 14/02/2022

... PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA.

1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guaíra

Foro de Guaíra

1ª Vara

Av. 17, 414, Guaíra - SP - cep 14790-000

1500145-02.2021.8.26.0210 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500145-02.2021.8.26.0210

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

José de Lourdes de Oliveira Neto e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDERSON VALENTE

Vistos.

I. JOSÉ DE LOURDES DE OLIVEIRA NETO, qualificado a fls. 20, foi denunciado e viu-se processado como incurso no artigo 33, caput c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343, de 23.08.2006, porque no dia 3 de março de 2021, por volta das 10h45min, na Avenida 33 nº 1, nesta cidade e Comarca de Guaíra, conluiado e mediante unidade de

desígnios com o adolescente N.A.O.S., teriam trazido consigo e em depósito, para finalidade de entrega ao consumo de terceiros, nove porções de cocaína, com peso bruto de 10 g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que “nas circunstâncias acima descritas, os policiais militares estavam em patrulhamento quando avistaram um veículo de cor preta no qual os ocupantes estavam entregando cédulas de dinheiro ao adolescente N. Ato contínuo, o adolescente estabeleceu contato com o denunciado, que por sua vez, se dirigiu até uma pilha de tijolos, pegou algo, e entregou ao condutor do veículo.

Nesse momento, ante a situação apresentada, os militares procederam abordagem no local. Em revista pessoal, encontraram com o adolescente a quantia de R\$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais) e 1 (um) Eppendorf contendo cocaína e com JOSÉ DE LOURDES apreenderam a quantia de R\$ 15,00 (quinze reais). Em seguida, os policiais se dirigiram até a pilha de tijolos onde o denunciado buscara algo ao condutor do veículo preto, ocasião em que os milicianos localizaram outros 8 (oito) Eppendorfs da mesma substância.

As circunstâncias que envolveram a prisão de JOSÉ DE LOURDES, notadamente a quantidade e natureza do entorpecente apreendido, bem como a movimentação do denunciado, evidenciam que os entorpecentes apreendidos eram destinados ao tráfico.”.

Denúncia de fls. 105/107 recebida em 21 de junho de 2021 (fls. 108). Devidamente citado (fls. 114), o Acusado apresentou defesa preliminar (fls. 126/127), rejeitada por não configurar o caso de absolvição sumária (fls. 128/130). Durante a instrução foi colhida prova oral e interrogado o Réu (fls. 161/169).

Em alegações finais o ilustre representante do Ministério Público pugnou pela condenação do Réu, nos exatos termos da denúncia (fls. 159/160).

A douta Defesa, por sua vez, ressaltou que não haveria prova apta a impor o édito condenatório, razão por que almejou sua absolvição (fls. 159/160).

Eis o relatório.

II. Fundamento e DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva ficou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/07), boletim de ocorrência de fls. 08/11, auto de exibição e apreensão de fls. 12/13, pelo laudo de constatação provisória de substância entorpecente (fls. 14/15), laudo de exame químico toxicológico (fls. 93/96), comprovante de depósito de fls. 100 e pela prova oral colhida durante a persecução penal.

A autoria, por seu turno, é certa e indicativa que o Réu praticou o delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, com a causa especial de aumento de pena do artigo 40, inciso VI, do mesmo diploma legal. Ouvido em Juízo, o Acusado negou o teor da denúncia, sustentando que jogava sinuca com seu irmão, Natan, quando os policiais chegaram no interior do bar, os retirando e colocando sentados em uma pilha, oportunidade em que eles pegaram o entorpecente e falaram que era deles. Ademais, disse não ter conversado com o motorista de outro veículo, trabalha com ferragens e que não é usuário de drogas (fls. 167/169).

Sua versão não convence e ficou isolada do contexto probatório, pois, caso verdadeira, faria ampla produção probatória a este respeito, inclusive fazendo ouvir outras pessoas que estivessem no bar, as quais com certeza iriam reproduzir sua alegação de que estava no bar jogando sinuca e de lá foi retirado.

De fato, os policiais militares Marcelo (fls. 161/163) e Rogério (fls. 164/166), em linhas gerais destacaram que estavam em patrulhamento quando se depararam com o Réu e o adolescente, seu irmão, conhecidos pela traficância, em ponto de venda de drogas, quando chegou um automóvel de cor preta e o adolescente fez contato, pegou algo aparentando ser dinheiro, conversou com o Réu e foi até uma pilha de tijolos próxima, pegando algo e entregando ao motorista daquele veículo, que saiu em alta velocidade, não conseguindo ver quem o dirigia, tampouco a placa. Nisso o Réu e seu irmão entraram no bar e foram abordados, sendo que com seu irmão localizaram um eppendorf contendo cocaína e dinheiro, ao passo que com o Réu localizaram R\$ 15,00. Na aludida pilha de tijolos encontraram oito eppendorfs contendo cocaína no exato lugar onde eles mexiam. Por fim, declararam que somente os dois estavam no local e não aparentavam estar sob efeito de drogas.

Nem se olvide pelo fato de a acusação se embasar somente no depoimento prestado por policiais, que é válido e está em consonância com as demais provas, sem existência de qualquer indicativo de sua imprestabilidade, motivo por que não podem ser descartados, notadamente porque o Réu não ofertou qualquer resistência ao depoimento deles, nem mesmo os contraditando.

A condição funcional não os torna suspeitos, valendo, outrossim, o princípio de presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados. Nesse diapasão, "Com relação aos depoimentos de policiais, os entendimentos jurisprudenciais têm convergido na direção de que são eles válidos e aptos ao suporte de uma condenação, pois aqueles agentes da autoridade prestam os seus esclarecimentos sob o compromisso da verdade como qualquer testemunha e as suas narrativas devem ser entendidas como verdadeiras até a produção de provas em contrário, com demonstração da falácia, recaindo o ônus da produção destas na esfera da defesa, situação que inocorreu nos autos.

Pequenas divergências encontradas no cotejo dos depoimentos prestados pelos policiais, sem atingirem o âmago da questão, devem ser desprezadas, posto que podem ser produto do posicionamento dos mesmos quando da diligência efetuada e das tarefas de cada um deles naquele momento, além do entrelaçamento de situações diante do elevado número de ocorrências que tais policiais atendem no dia a dia, sem o comprometimento daquilo que narraram" (TJSP, Ap. 990.08.168537-0, 10ª C.D.Crim., Rel. Des. Otávio Henrique, j. 16.04.2009).

A conduta do Acusado indica, pois, que no dia, horário e local apontados na denúncia, trazia consigo e tinha em depósito considerável quantidade de substância entorpecente para fins de traficância, envolvendo, ainda, um adolescente na criminalidade. A isso se chega com a prova coligida aos autos, notadamente a quantidade de cocaína apreendida, em frascos individuais pontos para comercialização, bem como a forma como estava o narcótico guardado, além do fato de que policiais militares avistaram o Réu e o adolescente remexendo no exato local onde encontradas as porções de cocaína, sendo ambos conhecidos dos meios pela prática do narcotráfico, ali um notório ponto de venda de drogas.

Tais condutas apontam que o Réu e o adolescente iriam utilizar o entorpecente apreendido para fins de mercantilização, consoante se extrai do artigo 28, parágrafo 2º, da Lei 11.343, de 23.08.2006.

Dessa forma, considerando o quadro posto, descabe se falar em insuficiência probatória. Oportuno salientar que não havia necessidade de o entorpecente estar junto ao corpo do Réu e "Nunca é demais lembrar, de outro lado, que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige resultado" (TJSP, Ap. 990.09172372-0, 5ª C.D.Crim., Rel. Des. Pinheiro Franco, j. 03.12.2009).

Forçoso se reconhecer, outrossim, que o Acusado, em sua prática nefasta, envolveu o

adolescente N.A.O.S. (cf. fls. 09). Assim, perfeitamente caracterizada a causa de aumento de pena tipificada no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06.

Diante desse quadro probatório, não há como se deixar de reconhecer que no dia, horário e local indicados na denúncia o Acusado foi surpreendido, quando trazia consigo e tinha em depósito, para fins de comercialização, a substância entorpecente descrita na inicial, tendo envolvido adolescente na prática criminosa.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do agente ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito e passo à dosimetria da pena.

O Réu não ostenta antecedentes criminais certificados nos autos que possam ser considerados para exasperação da pena-base (cf. fls. 152/153), agindo com dolo normal do delito, com o que fixo sua pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no menor valor, à míngua da comprovação de suas condições financeiras.

Na segunda fase da dosimetria, muito embora o Réu fosse menor de vinte e um anos de idade à época da consumação do crime a pena, mantida em seu piso, não pode ser diminuída aquém de seu patamar mínimo na segunda fase da dosimetria, uma vez ser mera circunstância atenuante (artigo 65, inciso I, do Código Penal). Esta orientação levou o C. Superior Tribunal de Justiça, inclusive, a editar a Súmula nº 231: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Por outro lado, rejeito a pretensão de majoração da pena com base no artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, porque não há qualquer indicação de que tenha o Réu se aproveitado da pandemia para praticar o crime de tráfico, não se verificando relação direta deste período de exceção com a prática do ilícito, não se podendo admitir interpretação extensiva a ponto de se exacerbar a condenação somente pelo momento em que praticado o delito, sob pena de se tornar padrão para todo e qualquer crime praticado durante o tempo em que grassar a peste. Nesse diapasão: "HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (16,8 G DE COCAÍNA E 35,3 G DE MACONHA). FIXAÇÃO DA PENA-BASE. DOSIMETRIA DA PENA. ARTS. 59 E 68 DO CP. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE LIMITES LEGAIS MÁXIMOS E MÍNIMOS. PATAMAR DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AGRAVANTES E ATENUANTES. ART. 61, II, J, DO CP. CALAMIDADE PÚBLICA. CONTEXTO DE PANDEMIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE.

1. Quando a quantidade ou a variedade da droga não é significativa, não há falar em exasperação da pena-base, sob pena de ofensa ao princípio da proporcionalidade.

2. A incidência da agravante do art. 61, II, j, do Código Penal exige demonstração de que o agente se valeu do contexto de pandemia para prática do delito.

3. O art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 exige que o paciente seja primário e de bons antecedentes, condição essa não preenchida pelo paciente.

4. Ordem parcialmente concedida para redimensionar a pena a 5 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, e 530 dias-multa, à razão mínima, pelos fundamentos declinados" (STJ, HC 654.255/SP, 6ª Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 25.05.2021 - grifei).

À derradeira, em vista da incidência da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, majoro sua pena em 1/6, à míngua de critérios que indicassem possibilidade de se aumentar a pena acima da fração mínima, e a fixo em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em seu piso legal.

Não havendo qualquer demonstração nos autos de que se dedique à atividade criminosa organizada, considerando que ficou demonstrado possuir ocupação lícita, malgrado praticasse concomitantemente o narcotráfico, faz jus à causa de diminuição da pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. No caso dos autos, dadas as circunstâncias particulares, não havendo qualquer demonstração clara de tratar-se de pessoa envolvida com a criminalidade organizada, reduz a pena no patamar máximo de 2/3 (dois terços), totalizando 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no seu piso, que torno definitiva ante a inexistência de demais causas legais modificadoras.

Neste ponto, é de se reconhecer que o Pleno do Supremo Tribunal Federal decidiu que o tráfico privilegiado não tem natureza de crime equipado ao hediondo, verbis:

"HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA.

1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos.
2. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa.
3. Há evidente constrangimento ilegal ao se estipular ao tráfico de entorpecentes privilegiado os rigores da Lei n. 8.072/90.
4. Ordem concedida" (HC118.533/MS, Relª Minª Carmen Lúcia, j. 23.06.2016).

Desta forma, tomando por base a ausência de hediondez do tráfico privilegiado, assim como sua primariedade e menoridade relativa, sua pena deverá ser cumprida desde o início em regime aberto, o que é aqui consignado por determinação legal (artigo 59, inciso III, do Código Penal) e em face de eventual e futura revogação das penas restritivas de direitos sobre as quais se falará a seguir. Presentes os requisitos previstos no artigo 44 e no seu parágrafo 2º, segunda parte, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniária de 1 (um) salário mínimo em favor de entidade assistencial (artigo 43, inciso I, do Código Penal) e prestação de serviço à comunidade ou entidade pública (artigo 43, inciso IV, do Código Penal), pelo prazo da condenação, que devem ter seu cumprimento fixado pelo Juízo das Execuções Criminais.

Lado outro, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando o artigo 387, inciso IV, do CPP, porquanto o crime apurado é classificado como vago, assim entendido aquele que tem por sujeito passivo a sociedade, destacando, outrossim, que não se comprovou qualquer dano causado em sujeitos passivos secundários (pessoa submetida aos riscos da lesão).

À derradeira, tendo em vista que o Acusado foi condenado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, sendo com ele localizada quantia em dinheiro vinculada ao crime, evidenciando-se ser o numerário fruto da venda de drogas ilícitas, com fulcro no artigo 63, caput, do aludido diploma legal, decreto a perda dos valores apreendidos com o Réu, depositados em Juízo (fls. 100 – R\$ 15,00), que deverão ser encaminhados em favor da União, com o trânsito em julgado desta sentença (artigo 63, parágrafo 1º).

III. Isto posto e tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e, em consequência CONDENO o Réu JOSÉ DE LOURDES DE OLIVEIRA NETO, qualificado nos autos, à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, com correção monetária a partir do fato delituoso, como incurso no artigo 33, caput

c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, em regime aberto, sendo que a pena de reclusão é substituída, por igual prazo, por pagamento de 1 (um) salário mínimo à entidade assistencial desta Comarca e à prestação de serviço à comunidade ou à entidade pública, a ser fixada pelo Juiz das Execuções Criminais. No mais, decreto o perdimento do valor apreendido com ele, depositado em fls. 100 (R\$ 15,00) em favor da União.

Após o trânsito em julgado, lancem seus nomes no Rol dos Culpados (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) e encaminhe-se o dinheiro apreendido em fls. 100 (R\$ 15,00) em favor da União.

Tendo em vista o regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não se mostra necessária a decretação de sua prisão cautelar, podendo aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade, nos termos do artigo 387, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

São devidas custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Guaíra, 14 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA